

[16-1] [경고, 부서경고] 사항

1. 제 목 : 토공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ☞☞☞☞처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★3부 차장 토목3급 ZZZ(경고)
(현 소속 : ◁◁지역본부 ☒☒☒☒처 ◆◆◆◆부 차장 토목3급)
4. 내 용 :

○○○○본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 33]과 같이 「◆◆◆◆◆◆도시 3-※생활권 및 4-※생활권(일부) 조성공사」(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하고 있다.

[표 33] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
◆◆◆◆◆◆도시 3-※생활권 및 4-※생활권(일부) 조성공사	코*****주	123,640백만 원	2012.5.25.~ 2017.9.30.	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

위 관련자 토목 3급 ZZZ은 2015. 2. 3.부터 2017. 1. 31.까지 위 본부에 근무하면서 위 공사의 감독원으로서 설계변경 등의 업무를 수행하였다.

2015. 6. 3. 본부에서는 위 공사 착공(2012. 5. 25.) 후 사토장 변경 시(2012. 12. 20.)까지 시행한 토공사에 대하여 현장여건 변동에 따른 ‘토량 정상별 이동 변경’이 발생하여 실제 정상별 이동을 반영한다는 사유로 985백만 원의 공사비를 증액하는 설계변경 방침을 결정하였다.

가. 계약조건에 따른 사후 설계변경 요건

「공사계약 일반조건」에 따르면 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 하며, 운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 증액 조정하여야 할 필요가 있는 경우 계약상대자의 신청에 의거 변경되는 부분의 이행에 착수하기 전에 계약내용 변경을 완료하여야 한다. 다만, 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계 및 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고 설계 및 계약내용 변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

아울러 계약상대자는 공사의 이행 중 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체 없이 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 公社와 공사 감독자에게 동시에 이를 통지하여야 하고, 公社는 통지를 받은 즉시 현장을 확인 하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

따라서 위 공사 수급인은 2012. 5. 25. 착공 후 공사현장의 상태가 설계서와 달라 ‘토량 성상별 이동 변경’에 따른 설계변경 및 계약금액 증액 조정이 필요했다면 계약조건에 따라 즉시 실정 보고 등을 통해 그 사실을 본부에 통지하여야 했다.

그런데 2015. 3. 10.⁴⁰⁾까지 위 공사 ‘토량 성상별 이동 변경’과 관련된 실정 보고가 본부에 접수된 사실이 없고, 감사 과정에서 수급인에게 해당 기간 동안 수급인이 公社 또는 공사감독자에게 문서 여부와 관계없이 관련 통지 또는 보고를 한 사실이 있는지를 질의하였으나 수급인은 관련 문서 및 자료를 찾을 수 없다고 확인⁴¹⁾하였다.

40) 2015. 3. 10. 위 공사 수급인 코*****㈜는 착공 후 처음으로 토량 성상별 이동 변경에 관한 실정보고를 본부에 제출하였고, 이에 따라 본부에서는 위 설계변경 방침결정을 하였음

아울러 해당 기간 위 공사의 감독자로 근무한 직원들의 진술에 따르면 당시 ‘토량 성상별 이동 변경’과 관련해서 수급인과 협의하여 설계변경의 시기 등을 정하고 우선 시공을 하게 한 사실이 없으며, 수급인으로부터 문서 또는 문서 이외의 형태로 관련 실정 보고를 받은 사실이 없다고 진술하였다.

이와 같이 위 공사의 ‘토량 성상별 이동 변경’은 「공사계약 일반조건」에 따른 사후 설계변경 대상이 아닌데도 본부에서는 해당 공사의 시공이 완료된 2015. 6. 3.에 설계변경을 하였다.

나. 신의·성실의 원칙 등 설계변경의 타당성

계약상대자가 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하였고 설계변경의 타당성과 불가피성이 인정된다면 비록 「공사계약 일반조건」에 따른 요건을 갖추지 못했더라도 설계변경 가능 여부를 신중히 검토할 필요가 있다.

본부에서는 착공 초기 토공사가 시급하고 사토 반출 여건이 어려워 운반비가 짙 토사·리핑암의 근거리 단지 내 성토가 불가피했기 때문에 이후 운반비가 비싼 발파암을 원거리 외부 사토장으로 반출할 수밖에 없었으므로 설계변경이 필요하다고 주장하였다.

41) 다만, 감사 종료 후 2017. 7. 6. 수급인이 제출한 소명서에 따르면 2013. 1월에 현장소장이 공사감독자에게 관련 실정보고를 제출하고 설명하였다고 주장한다. 그러나 관련 문서는 존재하지 않고 당시 담당자의 PC에 저장된 엑셀 파일(최종 수정일자 : 2013. 1. 24.)만을 확인하였다. 당시 현장소장은 실정보고를 문서로 접수하지 않은 사유는 기억나지 않는다고 진술했다. 동 실정보고 파일에서 제시한 설계변경 사유 중 ‘사토장 변경’에 대해서는 2013. 8월 설계변경 시 반영되었고, 본 건과 관련된 ‘단지성토 우선 시공’에 대해서는 반영되지 않았다. 따라서 수급인이 실정보고 문서는 접수하지 않았지만 관련 자료를 공사감독자에게 제출하였다고 인정하더라도 공사 감독자는 ‘단지성토 우선 시공’에 대해서는 승인하지 않은 것으로 볼 수밖에 없다. 아울러 본 건은 2012. 12. 20.까지 시행한 토공사에 대한 설계변경을 다루고 있으므로, 수급인의 주장대로 2013. 1월에 실정보고를 하였다면 이미 설계변경이 필요한 부분의 시공이 완료된 뒤에 실정보고를 한 것이므로 「공사계약 일반조건」에 따른 사후 설계변경 대상이 될 수 없다.

국책연구기관 부지 인계를 위하여 토공사가 시급했고 당초 설계서에 반영된 지정 사토장(3-※ 및 3-※생활권)의 사토 반입 여건이 어려웠다는 것은 인정된다.

위 공사 계약문서인 현장설명서에는 “정부 출연 연구기관 청사부지 등의 토지 사용시기 및 입주 시기 등을 고려한 공정계획을 수립하여 공사 준공 전이라도 청사 건축, 관련 도로의 개통 및 상·하수도 등 기반시설 공급, 청사 입주 등에 차질이 없도록 조치하여야 함”이라고 명시되어 있으므로 부지 인계 일정 준수는 수급인이 입찰 시부터 인지하고 있던 계약조건으로서 수급인의 의무였다.

착공 후 지정 사토장의 사토 반입 여건으로 인해 설계서에 따른 토석 운반에 어려움이 있었다고 인정하더라도 수급인이 ‘권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다’는 신의와 성실의 원칙에 따라 반드시 실정보고를 하여야 했던 이유는 다음과 같다.

당시 수급인의 실정보고가 있었다면 본부에서는 계약조건과 현장 여건을 파악하여 검토 결과에 따라 당초 설계서대로 시공하도록 하거나, 만약 설계서의 변경이 필요하다면 즉시 대체 사토장 지정, 토사 가적치, 성상별 이동량 변경 등 여러 가지 대안을 검토하여 당시 본부 내 토사 부족 상황과 공사비 증감액 등을 종합적으로 판단하여 대책을 강구할 수 있었다.

「공사계약 일반조건」 및 公社의 관련 지침 등에서 시공 전에 설계변경을 완료하도록 하고, 긴급한 경우에도 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고 우선 시공하도록 엄격히 규정하고 있는 것은 위와 같은 대안 검토 등의 절차 없이 미리 시공이 이루어질 경우 불필요한 공사비의 낭비 등을 초래할 수 있고 계약상대자의 일방적인 공사 시행 후 공사비 증액 요구 등 계약질서가 심각하게 훼손될 수

있기 때문일 것이다.

만약 실제로 토사와 암석의 성상별 운반량이 일부 변경되어 시공되었더라도 문서 수·발신 현황 등 증거자료와 전임 감독자 및 수급인의 진술 등을 고려할 때 수급인은 현장 여건 불일치에 따른 실정보고를 하지 않았고, 이에 따라 설계 변경의 적정 여부 및 경제성 있는 대안에 대한 검토가 이루어지지 않은 채 수급인이 설계서와 다르게 토석을 운반한 것이다.

이와 같이 수급인이 신의와 성실의 원칙에 입각한 의무는 이행하지 않은 채 설계서의 성상별 토석 운반 계획과 다르게 시공할 수밖에 없었다고 주장하면서 이미 시공이 완료된 이후 물량 확정이 불가능한 시점에 公社에 증액 설계변경을 요구하는 것은 권리의 행사를 위해 의무를 이행하여야 한다는 신의와 성실의 원칙에 위배된다.

다. 공사의 긴급성 등 시공 당시의 상황

수급인은 2012년 당시 공사의 긴급성과 본부 분위기로 인하여 ‘운반 변경에 따른 공사비는 일부 증가될 것으로 생각했지만 공사를 중지하여 놓고 공사비를 先 검토할 수 있는 상황이 아니었다’고 주장한다.

긴급한 공사상황이 끝난 뒤 2013. 8. 28. 본부에서는 위 공사의 사토장 변경(3생활권→4생활권)에 따른 성상별 토석 운반 계획 변경, 발파암 물량 증가 등을 포함하여 토량유용계획을 전면 변경하는 설계변경(공사비 증 2,172백만 원)을 하였고, 2014. 10. 13. 감사 지적사항 등을 반영하여 토량유용계획을 다시 변경하는 설계변경(공사비 감 1,097백만 원)을 하였다.

수급인은 성상별 토석 운반 계획을 포함하여 토량유용계획을 전면 변경한 위 두 차례 설계변경에서 ‘토량 성상별 이동 변경’에 대하여 이의를 제기하지 않은 채 公社와 변경 계약을 체결하였다.

아울러 수급인은 착공 후 2015. 6. 3. 위 설계변경을 하기 전까지 총 30회에 걸쳐 ‘토량 성상별 이동 변경’에 대한 개산급 신청을 하지 않은 채 직접 성상별 토석 운반량을 산정하여 公社에 기성부분에 대한 대가의 지급을 요청하였으며, 본부에서는 기성부분에 대한 검사를 거쳐 기성부분 물량을 확정하여 그 대가를 지급하였고 수급인은 이를 그대로 수령하였다.

위와 같이 수급인은 2012년 긴급한 공사상황이 끝난 뒤에도 2015. 3월⁴²⁾까지 사토장 변경에 따른 성상별 토석 운반량 변경 등 관련 계약 변경을 두 차례 시행하고 성상별 토석 운반량을 직접 산정하여 22차례의 기성 대가를 청구·수령하면서도 ‘토량 성상별 이동 변경’에 대한 실정보고를 하지 않았다.

그러므로 2012년 당시 공사비를 先 검토할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 실정보고를 할 수 없었다는 수급인의 주장은 받아들일 수 없다.

라. 물량확정 및 설계변경 시 수량산출 근거

토량은 토공 횡단도를 작성하여 양단면 평균법 등의 토적계산법에 따라 산출하고 토석의 성상별 운반량은 토량유용계획에서 산정하여 토적계산서에 포함하여야 한다.

42) 2015. 3. 10. 수급인은 착공 후 처음으로 토량 성상별 이동 변경에 관한 실정보고를 본부에 제출하였고, 이에 따라 본부에서는 위 설계변경 방침결정을 하였음

매몰된 부분의 토공 물량은 측량 등에 의해 확정된 기성부분 검사조서를 통해 확인할 수 있으며, 이미 토공사가 완료된 상태에서는 현실적으로 시공 당시의 성상별 토석 운반량을 확인할 수 있는 방법이 없다.

본부와 수급인은 성상별 토석 운반량과 관련하여 시공 당시와 시공 후에라도 측량 등을 통하여 물량을 확인할 수 있었던 기간에는 당시 설계서대로 기성부분 수량을 확정하였다.

기성검사 내역을 보면 2012. 12월까지 토사와 리핑암의 단지 내 성토·운반량은 약 230만 m^3 가량이고 이후 발파암 등으로 성토가 추가로 이루어진 것으로 되어있다.

그런데 본부에서는 토적표상 단지 내 총 성토량(약 443만 m^3) 중에서 2012. 12월 기성내역 기준 발파암 성토량(약 60만 m^3)⁴³⁾을 제외한 나머지 물량(약 383만 m^3)은 2012. 12월까지 토사와 리핑암으로 성토가 완료된 것으로 추정함으로써, 발파암 잔여 발생량을 모두⁴⁴⁾ 외부에 사토한 것으로 산정하여 이미 설계 변경된 물량을 제외한 추가물량(422천 m^3)에 대하여 운반거리를 변경(단지내 성토 → 외부 사토)하였다.

이와 같이 설계변경 및 기성검사 등을 통해 토공량이 확정되었고 시공이 완료되어 물량을 확인할 수 없는 시점에 측량 등의 물량 확정 방법에 의하지 않은 채 검증할 수 없는 非정량적 정황을 근거로 시공량을 추정하여 이미 확정된 성상별 토석 운반량을 변경하는 것은 부적정하다.

43) 2012. 12월 기성내역 기준 단지내 발파암 성토량

44) 발파암 유용물량(약 21만 m^3)은 제외

마. 기술심의 지역설계변경분과위원회 운영

2015. 3. 10. 위 공사 수급인 코*****㈜는 착공 후 처음으로 ‘단지 내 토공 운반 수량 정산 실정보고’를 본부에 제출⁴⁵⁾하였고, 동 실정보고에는 설계변경이 필요한 성상별 토석 운반량이 681천³이고 증액 공사비는 약 1,311백만 원인 것으로 되어있다.

위 관련자는 설계변경 대상 물량과 공사비를 각각 422천³, 985백만 원⁴⁶⁾으로 조정하여 설계변경방침(안)을 작성하였고 2015. 4. 9. 본부 ★★★★★1부에 지역 설계변경분과위원회 심의를 요청하였다.

본부에서는 2015. 4. 15. 심의위원 10명 중 8명이 참석하여 지역설계변경분과위원회를 개최하였으나 참석한 심의위원 전원이 설계변경 및 수량산출의 근거 부족, 사전협의 미이행 및 설계변경 시기 부적정, 감사실 사전 협의 필요 등을 사유로 재심의 의견을 제시함에 따라 심의결과는 ‘재심의’로 의결되었다.

관련자는 위 심의의견에 대한 조치결과를 [표 34]와 같이 작성하여 2015. 5. 18. 지역설계변경분과위원회 재심의를 요청하였고, 재심의 결과 참석한 8명의 심의위원 중 2명이 재심의 및 조건부적격 의견⁴⁷⁾을 제시하였으나 나머지 6명이 적격 의견을 제시함에 따라 출석인원 다수결로 심의결과는 ‘적격’으로 의결되었다.

45) 본부 문서대장 및 관련 문서철에는 해당 실정보고 문서가 접수된 기록이 없고 수급인도 감사기간 중 관련 실정보고 문서를 찾지 못했으나, 본부에서 수급인에게 보낸 설계변경 시행 통보 문서에 실정보고 문서번호가 기록되어 있음에 따라 관련 자료를 찾던 중 감독사무소에 별도로 보관된 문서를 발견하였음.

46) 「감사기준 시행세칙」 제16조에 따라 1,000백만 원 이상의 설계변경은 일상감사 대상임.

47) 조건 또는 사유 : 설계변경 당위성 및 근거자료 미흡, 수급업체가 주장하는 4-※생활권 내 암랑 확인 필요

[표 34] 지역설계변경분과위원회 심의의견 조치결과

심의의견	조치결과	비고
토량성상별 이동거리 정산에 대한 근거부족으로 객관적 근거 제시 필요	토량 성상별 이동거리 정산에 대한 근거 보완자료 작성 (시공사에서 작성 및 재심의시 제출)	
설계변경 방침 시행시기에 대한 적정여부 재검토 필요	토량이동 변경에 대한 사실 확인 후 방침시행은 가능 (감사실 의견)	
이동거리 변경을 위한 사전 협의 및 승인을 득하지 못한 사유 보강 필요	시급한 공사일정 및 대체사토장 지정 지연 등 당시 시공여건에 대한 전임 감독원 의견서 제출	
동 건의 타당여부에 대한 감사실 의견 청취 필요	감사실 의견청취 완료	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

심의의견 중 근거 부족에 대해서는 위 공사 단지 내 5개 성토블록의 지반조사 보고서와 토공 시공 사진을 보완자료로 제시하며 단지 내 성토가 대부분 토사로 이루어졌음을 주장하였다.

그러나 ‘라’에서 살펴본 바와 같이 기성검사 등을 통해 토공량이 확정되었고 시공이 완료되어 물량을 확인할 수 없는 시점에 非정량적인 정황을 근거로 시공량을 추정하여 이미 확정된 성상별 토석 운반량을 변경하는 것은 부적정하다.

감사실 협의에 대하여는 “사실 확인이 가능한 객관적 증빙자료 확보 등 사실 확인 후 정산 시행은 원칙적으로 타당하다”는 감사실 의견을 청취하였다고 주장하지만, 토공량 ‘정산’의 원칙에 대한 구두 의견을 위 설계변경 타당성에 대한 감사실 의견이라고 볼 수 없고 설계변경의 근거가 될 수 없다.

사후 설계변경의 사유에 대하여는 “성상별 토량이동 변경이 실제 발생하였고 불가피하였다”는 전임 감독원의 의견서를 제시하였으나, ‘가’~‘다’에서 살펴본 바와 같이 당시 시공 여건을 일부 인정하더라도 계약조건상 설계변경의 요건과

신의·성실의 원칙에 따른 타당성을 갖추지 못한 상태에서 이전의 설계변경 및 기성검사 등을 통해 확정된 토공량을 설계 변경하는 것은 부적정하다.

아울러 수급인 코***** (주)는 본부 지역설계변경분과의위원회 심의 결과가 ‘재심의’로 의결되자 [표 35]와 같은 내용의 동의서를 본부에 제출하였다.

[표 35] 동의서 제출 현황

제 출 자	코***** (주) 대표이사
제출일자	2015. 5. 18.
내 용	당 사가 제출한 토량이동 중간정산 실정보고에 따른 설계변경방침 및 계약변경이 완료된 이후라도 LH 내부감사 또는 감사원감사 등 내·외부 감사 시 설계변경이 부적정한 것으로 지적되는 경우에는 이를 수인하고 계약변경 후 지급된 금액에 대하여는 전액 환입하는 것에 동의합니다.

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

바. 결론 및 부당한 설계변경에 따라 지급된 공사비의 회수

위에서 살펴본 바와 같이 계약조건 상 수급인의 의무인 토지사용시기 준수를 위하여 수급인이 실정보고 및 公社의 승인 없이 토석 운반을 설계서와 다르게 임의로 시공하였다면 설사 ‘토량 성상별 이동 변경’이 일부 발생하였더라도 사후 설계변경 대상이 될 수 없다.

그런데 본부에서는 시공완료 및 물량확정 후 매몰되어 실제 시공량을 확인할 수 없는 시점에 수급인의 요구에 의해 성상별 토석 운반량을 추정하여 부당하게 설계 변경함으로써 계약질서를 훼손하고 예산낭비를 초래하였다.

따라서 부적정한 설계변경으로 인해 수급인에게 과다 지급된 공사비를 회수할

필요가 있으므로 이와 같은 조치가 거래상 지위남용 등 불공정 행위에 해당하는지에 대해 검토할 필요가 있다.

2015. 5. 7. 공정거래위원회는 公社가 자체 종합감사를 통하여 이미 설계 변경되어 공사가 완료되었음에도 「공사계약 특수조건」을 근거로 품셈적용의 착오 등 단가 적용의 문제점을 들어 공사비를 감액한 3건의 감사처분에 대하여 ‘정상적 절차에 따라 계약된 공사비를 소급하여 감액하는 행위는 거래의 안정성을 크게 해치고 거래상대방에게 불이익을 주는 행위’라면서 公社에 대하여 ‘거래상 지위남용 행위’에 대한 시정조치 및 과징금 부과 처분을 하였다.

그러나 公社는 처분의 위법성·부당성을 다투고자 처분 취소를 구하는 소송을 제기하여 [표 36]과 같은 취지로 위의 시정조치 및 과징금 부과 처분에 대한 취소 판결을 받았다.

[표 36] 공정위 처분에 대한 소송 판결 취지

사건 처분의 적법 여부에 관한 판단
공사계약특수조건이 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건에 해당하지 않는 한 <u>이미 설계가 변경되어 시공이 완료된 이후라고 하더라도</u> 종전에 잘못 산정된 공사비에 대하여 <u>공사계약특수 조건에 따라</u> 단순한 오류를 바로잡는 차원에서 <u>조정 또는 환수하는 것이 가능</u> 하다고 판단되고, 오류 금액을 조정하거나 환수하였다고 하여 원고가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방에게 불이익을 준 것이라고 보기는 어렵다

자료 : 最高法院 判決文(2016. 12. 14.) 재구성 (공정위에서 대법원 상고하였으나 2017. 5. 12. 기각)

설계변경 및 시공 완료 이후라고 하더라도 잘못 산정된 공사비에 대하여 계약 조건에 따라 환수하는 것이 가능하며 이는 상대방에게 불이익을 주는 것이 아니라는 판결 취지를 고려할 때, 계약조건에 따라 설계변경 대상이 되지 않는에도 시공 완료 후 부당한 설계변경을 함으로써 과다하게 지급된 공사비를 회수하는 조치

는 적법하며 불공정 행위에 해당되지 않는다고 판단된다.

5. 조치할 사항

❧❧❧❧처장은

① 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 토목3급 ZZZ에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시고(경고),

② 기술심의 지역설계변경분과위원회 운영을 소홀히 한 ○○○○본부에 대해 ‘부서경고’ 조치하시기 바랍니다(부서경고).

[16-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 토공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 37]과 같이 「◆◆◆◆◆도시 3-※생활권 및 4-※생활권(일부) 조성공사」(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하고 있다.

[표 37] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
◆◆◆◆◆도시 3-※생활권 및 4-※생활권(일부) 조성공사	코*****주	123,640백만 원	2012.5.25.~ 2017.9.30.	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

관련자 토목 3급 ZZZ은 2015. 2. 3.부터 2017. 1. 31.까지 위 본부에 근무하면서 위 공사의 감독원으로서 설계변경 등의 업무를 수행하였다.

2015. 6. 3. 본부에서는 위 공사 착공(2012. 5. 25.) 후 사토장 변경 시(2012. 12. 20.)까지 시행한 토공사에 대하여 현장여건 변동에 따른 ‘토량 정상별 이동 변경’이 발생하여 실제 정상별 이동을 반영한다는 사유로 985백만 원의 공사비를 증액하는 설계변경 방침을 결정하였다.

가. 계약조건에 따른 사후 설계변경 요건

「공사계약 일반조건」에 따르면 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 하며, 운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 증액 조정하여야 할 필요가 있는 경우 계약상대자의 신청에 의거 변경되는 부분의 이행에 착수하기 전에 계약내용 변경을 완료하여야 한다. 다만, 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계 및 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고 설계 및 계약내용 변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

아울러 계약상대자는 공사의 이행 중 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체 없이 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 公社와 공사 감독자에게 동시에 이를 통지하여야 하고, 公社는 통지를 받은 즉시 현장을 확인 하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

따라서 위 공사 수급인은 2012. 5. 25. 착공 후 공사현장의 상태가 설계서와 달라 ‘토량 성상별 이동 변경’에 따른 설계변경 및 계약금액 증액 조정이 필요했다면 계약조건에 따라 즉시 실정 보고 등을 통해 그 사실을 본부에 통지하여야 했다.

그런데 2015. 3. 10.⁴⁸⁾까지 위 공사 ‘토량 성상별 이동 변경’과 관련된 실정 보고가 본부에 접수된 사실이 없고, 감사 과정에서 수급인에게 해당 기간 동안 수급인이 公社 또는 공사감독자에게 문서 여부와 관계없이 관련 통지 또는 보고를 한 사실이 있는지를 질의하였으나 수급인은 관련 문서 및 자료를 찾을 수 없다고 확인⁴⁹⁾하였다.

48) 2015. 3. 10. 위 공사 수급인 코*****㈜는 착공 후 처음으로 토량 성상별 이동 변경에 관한 실정보고를 본부에 제출하였고, 이에 따라 본부에서는 위 설계변경 방침결정을 하였음

아울러 해당 기간 위 공사의 감독자로 근무한 직원들의 진술에 따르면 당시 ‘토량 성상별 이동 변경’과 관련해서 수급인과 협의하여 설계변경의 시기 등을 정하고 우선 시공을 하게 한 사실이 없으며, 수급인으로부터 문서 또는 문서 이외의 형태로 관련 실정 보고를 받은 사실이 없다고 진술하였다.

이와 같이 위 공사의 ‘토량 성상별 이동 변경’은 「공사계약 일반조건」에 따른 사후 설계변경 대상이 아닌데도 본부에서는 해당 공사의 시공이 완료된 2015. 6. 3.에 설계변경을 하였다.

나. 신의·성실의 원칙 등 설계변경의 타당성

계약상대자가 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하였고 설계변경의 타당성과 불가피성이 인정된다면 비록 「공사계약 일반조건」에 따른 요건을 갖추지 못했더라도 설계변경 가능 여부를 신중히 검토할 필요가 있다.

본부에서는 착공 초기 토공사가 시급하고 사토 반출 여건이 어려워 운반비가 짙 토사·리핑암의 근거리 단지 내 성토가 불가피했기 때문에 이후 운반비가 비싼 발파암을 원거리 외부 사토장으로 반출할 수밖에 없었으므로 설계변경이 필요하다고 주장하였다.

49) 다만, 감사 종료 후 2017. 7. 6. 수급인이 제출한 소명서에 따르면 2013. 1월에 현장소장이 공사감독자에게 관련 실정보고를 제출하고 설명하였다고 주장한다. 그러나 관련 문서는 존재하지 않고 당시 담당자의 PC에 저장된 엑셀 파일(최종 수정일자 : 2013. 1. 24.)만을 확인하였다. 당시 현장소장은 실정보고를 문서로 접수하지 않은 사유는 기억나지 않는다고 진술했다. 동 실정보고 파일에서 제시한 설계변경 사유 중 ‘사토장 변경’에 대해서는 2013. 8월 설계변경 시 반영되었고, 본 건과 관련된 ‘단지성토 우선 시공’에 대해서는 반영되지 않았다. 따라서 수급인이 실정보고 문서는 접수하지 않았지만 관련 자료를 공사감독자에게 제출하였다고 인정하더라도 공사 감독자는 ‘단지성토 우선 시공’에 대해서는 승인하지 않은 것으로 볼 수밖에 없다. 아울러 본 건은 2012. 12. 20.까지 시행한 토공사에 대한 설계변경을 다루고 있으므로, 수급인의 주장대로 2013. 1월에 실정보고를 하였다면 이미 설계변경이 필요한 부분의 시공이 완료된 뒤에 실정보고를 한 것이므로 「공사계약 일반조건」에 따른 사후 설계변경 대상이 될 수 없다.

국책연구기관 부지 인계를 위하여 토공사가 시급했고 당초 설계서에 반영된 지정 사토장(3-※ 및 3-※생활권)의 사토 반입 여건이 어려웠다는 것은 인정된다.

위 공사 계약문서인 현장설명서에는 “정부 출연 연구기관 청사부지 등의 토지 사용시기 및 입주 시기 등을 고려한 공정계획을 수립하여 공사 준공 전이라도 청사 건축, 관련 도로의 개통 및 상·하수도 등 기반시설 공급, 청사 입주 등에 차질이 없도록 조치하여야 함”이라고 명시되어 있으므로 부지 인계 일정 준수는 수급인이 입찰 시부터 인지하고 있던 계약조건으로서 수급인의 의무였다.

착공 후 지정 사토장의 사토 반입 여건으로 인해 설계서에 따른 토석 운반에 어려움이 있었다고 인정하더라도 수급인이 ‘권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다’는 신의와 성실의 원칙에 따라 반드시 실정보고를 하여야 했던 이유는 다음과 같다.

당시 수급인의 실정보고가 있었다면 본부에서는 계약조건과 현장 여건을 파악하여 검토 결과에 따라 당초 설계서대로 시공하도록 하거나, 만약 설계서의 변경이 필요하다면 즉시 대체 사토장 지정, 토사 가적치, 성상별 이동량 변경 등 여러 가지 대안을 검토하여 당시 본부 내 토사 부족 상황과 공사비 증감액 등을 종합적으로 판단하여 대책을 강구할 수 있었다.

「공사계약 일반조건」 및 公社의 관련 지침 등에서 시공 전에 설계변경을 완료하도록 하고, 긴급한 경우에도 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고 우선 시공하도록 엄격히 규정하고 있는 것은 위와 같은 대안 검토 등의 절차 없이 미리 시공이 이루어질 경우 불필요한 공사비의 낭비 등을 초래할 수 있고 계약상대자의 일방적인 공사 시행 후 공사비 증액 요구 등 계약질서가 심각하게 훼손될 수

있기 때문일 것이다.

만약 실제로 토사와 암석의 성상별 운반량이 일부 변경되어 시공되었더라도 문서 수·발신 현황 등 증거자료와 전임 감독자 및 수급인의 진술 등을 고려할 때 수급인은 현장 여건 불일치에 따른 실정보고를 하지 않았고, 이에 따라 설계 변경의 적정 여부 및 경제성 있는 대안에 대한 검토가 이루어지지 않은 채 수급인이 설계서와 다르게 토석을 운반한 것이다.

이와 같이 수급인이 신의와 성실의 원칙에 입각한 의무는 이행하지 않은 채 설계서의 성상별 토석 운반 계획과 다르게 시공할 수밖에 없었다고 주장하면서 이미 시공이 완료된 이후 물량 확정이 불가능한 시점에 公社에 증액 설계변경을 요구하는 것은 권리의 행사를 위해 의무를 이행하여야 한다는 신의와 성실의 원칙에 위배된다.

다. 공사의 긴급성 등 시공 당시의 상황

수급인은 2012년 당시 공사의 긴급성과 본부 분위기로 인하여 ‘운반 변경에 따른 공사비는 일부 증가될 것으로 생각했지만 공사를 중지하여 놓고 공사비를 先 검토할 수 있는 상황이 아니었다’고 주장한다.

긴급한 공사상황이 끝난 뒤 2013. 8. 28. 본부에서는 위 공사의 사토장 변경(3생활권→4생활권)에 따른 성상별 토석 운반 계획 변경, 발파암 물량 증가 등을 포함하여 토량유용계획을 전면 변경하는 설계변경(공사비 증 2,172백만 원)을 하였고, 2014. 10. 13. 감사 지적사항 등을 반영하여 토량유용계획을 다시 변경하는 설계변경(공사비 감 1,097백만 원)을 하였다.

수급인은 성상별 토석 운반 계획을 포함하여 토량유용계획을 전면 변경한 위 두 차례 설계변경에서 ‘토량 성상별 이동 변경’에 대하여 이의를 제기하지 않은 채 公社와 변경 계약을 체결하였다.

아울러 수급인은 착공 후 2015. 6. 3. 위 설계변경을 하기 전까지 총 30회에 걸쳐 ‘토량 성상별 이동 변경’에 대한 개산급 신청을 하지 않은 채 직접 성상별 토석 운반량을 산정하여 公社에 기성부분에 대한 대가의 지급을 요청하였으며, 본부에서는 기성부분에 대한 검사를 거쳐 기성부분 물량을 확정하여 그 대가를 지급하였고 수급인은 이를 그대로 수령하였다.

위와 같이 수급인은 2012년 긴급한 공사상황이 끝난 뒤에도 2015. 3월⁵⁰⁾까지 사토장 변경에 따른 성상별 토석 운반량 변경 등 관련 계약 변경을 두 차례 시행하고 성상별 토석 운반량을 직접 산정하여 22차례의 기성 대가를 청구·수령하면서도 ‘토량 성상별 이동 변경’에 대한 실정보고를 하지 않았다.

그러므로 2012년 당시 공사비를 先 검토할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 실정보고를 할 수 없었다는 수급인의 주장은 받아들일 수 없다.

라. 물량확정 및 설계변경 시 수량산출 근거

토량은 토공 횡단도를 작성하여 양단면 평균법 등의 토적계산법에 따라 산출하고 토석의 성상별 운반량은 토량유용계획에서 산정하여 토적계산서에 포함하여야 한다.

50) 2015. 3. 10. 수급인은 착공 후 처음으로 토량 성상별 이동 변경에 관한 실정보고를 본부에 제출하였고, 이에 따라 본부에서는 위 설계변경 방침결정을 하였음

매몰된 부분의 토공 물량은 측량 등에 의해 확정된 기성부분 검사조서를 통해 확인할 수 있으며, 이미 토공사가 완료된 상태에서는 현실적으로 시공 당시의 성상별 토석 운반량을 확인할 수 있는 방법이 없다.

본부와 수급인은 성상별 토석 운반량과 관련하여 시공 당시와 시공 후에라도 측량 등을 통하여 물량을 확인할 수 있었던 기간에는 당시 설계서대로 기성부분 수량을 확정하였다.

기성검사 내역을 보면 2012. 12월까지 토사와 리핑암의 단지 내 성토·운반량은 약 230만 m^3 가량이고 이후 발파암 등으로 성토가 추가로 이루어진 것으로 되어있다.

그런데 본부에서는 토적표상 단지 내 총 성토량(약 443만 m^3) 중에서 2012. 12월 기성내역 기준 발파암 성토량(약 60만 m^3)⁵¹⁾을 제외한 나머지 물량(약 383만 m^3)은 2012. 12월까지 토사와 리핑암으로 성토가 완료된 것으로 추정함으로써, 발파암 잔여 발생량을 모두⁵²⁾ 외부에 사토한 것으로 산정하여 이미 설계 변경된 물량을 제외한 추가물량(422천 m^3)에 대하여 운반거리를 변경(단지내 성토 → 외부 사토)하였다.

이와 같이 설계변경 및 기성검사 등을 통해 토공량이 확정되었고 시공이 완료되어 물량을 확인할 수 없는 시점에 측량 등의 물량 확정 방법에 의하지 않은 채 검증할 수 없는 非정량적 정황을 근거로 시공량을 추정하여 이미 확정된 성상별 토석 운반량을 변경하는 것은 부적정하다.

51) 2012. 12월 기성내역 기준 단지내 발파암 성토량

52) 발파암 유용물량(약 21만 m^3)은 제외

마. 기술심의 지역설계변경분과위원회 운영

2015. 3. 10. 위 공사 수급인 코*****㈜는 착공 후 처음으로 ‘단지 내 토공 운반 수량 정산 실정보고’를 본부에 제출⁵³⁾하였고, 동 실정보고에는 설계변경이 필요한 성상별 토석 운반량이 681천³이고 증액 공사비는 약 1,311백만 원인 것으로 되어있다.

위 관련자는 설계변경 대상 물량과 공사비를 각각 422천³, 985백만 원⁵⁴⁾으로 조정하여 설계변경방침(안)을 작성하였고 2015. 4. 9. 본부 ★★★★★1부에 지역 설계변경분과위원회 심의를 요청하였다.

본부에서는 2015. 4. 15. 심의위원 10명 중 8명이 참석하여 지역설계변경분과위원회를 개최하였으나 참석한 심의위원 전원이 설계변경 및 수량산출의 근거 부족, 사전협의 미이행 및 설계변경 시기 부적정, 감사실 사전 협의 필요 등을 사유로 재심의 의견을 제시함에 따라 심의결과는 ‘재심의’로 의결되었다.

관련자는 위 심의의견에 대한 조치결과를 [표 38]과 같이 작성하여 2015. 5. 18. 지역설계변경분과위원회 재심의를 요청하였고, 재심의 결과 참석한 8명의 심의위원 중 2명이 재심의 및 조건부적격 의견⁵⁵⁾을 제시하였으나 나머지 6명이 적격 의견을 제시함에 따라 출석인원 다수결로 심의결과는 ‘적격’으로 의결되었다.

53) 본부 문서대장 및 관련 문서철에는 해당 실정보고 문서가 접수된 기록이 없고 수급인도 감사기간 중 관련 실정보고 문서를 찾지 못했으나, 본부에서 수급인에게 보낸 설계변경 시행 통보 문서에 실정보고 문서번호가 기록되어 있음에 따라 관련 자료를 찾던 중 감독사무소에 별도로 보관된 문서를 발견하였음.

54) 「감사기준 시행세칙」 제16조에 따라 1,000백만 원 이상의 설계변경은 일상감사 대상임.

55) 조건 또는 사유 : 설계변경 당위성 및 근거자료 미흡, 수급업체가 주장하는 4-※생활권 내 암랑 확인 필요

[표 38] 지역설계변경분과위원회 심의의견 조치결과

심의의견	조치결과	비고
토량성상별 이동거리 정산에 대한 근거부족으로 객관적 근거 제시 필요	토량 성상별 이동거리 정산에 대한 근거 보완자료 작성 (시공사에서 작성 및 재심의시 제출)	
설계변경 방침 시행시기에 대한 적정여부 재검토 필요	토량이동 변경에 대한 사실 확인 후 방침시행은 가능 (감사실 의견)	
이동거리 변경을 위한 사전 협의 및 승인을 득하지 못한 사유 보강 필요	시급한 공사일정 및 대체사토장 지정 지연 등 당시 시공여건에 대한 전임 감독원 의견서 제출	
동 건의 타당여부에 대한 감사실 의견 청취 필요	감사실 의견청취 완료	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

심의의견 중 근거 부족에 대해서는 위 공사 단지 내 5개 성토블록의 지반조사 보고서와 토공 시공 사진을 보완자료로 제시하며 단지 내 성토가 대부분 토사로 이루어졌음을 주장하였다.

그러나 ‘라’에서 살펴본 바와 같이 기성검사 등을 통해 토공량이 확정되었고 시공이 완료되어 물량을 확인할 수 없는 시점에 非정량적인 정황을 근거로 시공량을 추정하여 이미 확정된 성상별 토석 운반량을 변경하는 것은 부적정하다.

감사실 협의에 대하여는 “사실 확인이 가능한 객관적 증빙자료 확보 등 사실 확인 후 정산 시행은 원칙적으로 타당하다”는 감사실 의견을 청취하였다고 주장하지만, 토공량 ‘정산’의 원칙에 대한 구두 의견을 위 설계변경 타당성에 대한 감사실 의견이라고 볼 수 없고 설계변경의 근거가 될 수 없다.

사후 설계변경의 사유에 대하여는 “성상별 토량이동 변경이 실제 발생하였고 불가피하였다”는 전임 감독원의 의견서를 제시하였으나, ‘가’~‘다’에서 살펴본 바와 같이 당시 시공 여건을 일부 인정하더라도 계약조건상 설계변경의 요건과

신의·성실의 원칙에 따른 타당성을 갖추지 못한 상태에서 이전의 설계변경 및 기성검사 등을 통해 확정된 토공량을 설계 변경하는 것은 부적정하다.

아울러 수급인 코***** (주)는 본부 지역설계변경분과의위원회 심의 결과가 ‘재심의’로 의결되자 [표 39]와 같은 내용의 동의서를 본부에 제출하였다.

[표 39] 동의서 제출 현황

제 출 자	코***** (주) 대표이사
제출일자	2015. 5. 18.
내 용	당 사가 제출한 토량이동 중간정산 실정보고에 따른 설계변경방침 및 계약변경이 완료된 이후라도 LH 내부감사 또는 감사원감사 등 내·외부 감사 시 설계변경이 부적정한 것으로 지적되는 경우에는 이를 수인하고 계약변경 후 지급된 금액에 대하여는 전액 환입하는 것에 동의합니다.

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

바. 결론 및 부당한 설계변경에 따라 지급된 공사비의 회수

위에서 살펴본 바와 같이 계약조건 상 수급인의 의무인 토지사용시기 준수를 위하여 수급인이 실정보고 및 公社의 승인 없이 토석 운반을 설계서와 다르게 임의로 시공하였다면 설사 ‘토량 성상별 이동 변경’이 일부 발생하였더라도 사후 설계변경 대상이 될 수 없다.

그런데 본부에서는 시공완료 및 물량확정 후 매몰되어 실제 시공량을 확인할 수 없는 시점에 수급인의 요구에 의해 성상별 토석 운반량을 추정하여 부당하게 설계 변경함으로써 계약질서를 훼손하고 예산낭비를 초래하였다.

따라서 부적정한 설계변경으로 인해 수급인에게 과다 지급된 공사비를 회수할

필요가 있으므로 이와 같은 조치가 거래상 지위남용 등 불공정 행위에 해당하는지에 대해 검토할 필요가 있다.

2015. 5. 7. 공정거래위원회는 公社가 자체 종합감사를 통하여 이미 설계 변경되어 공사가 완료되었음에도 「공사계약 특수조건」을 근거로 품셈적용의 착오 등 단가 적용의 문제점을 들어 공사비를 감액한 3건의 감사처분에 대하여 ‘정상적 절차에 따라 계약된 공사비를 소급하여 감액하는 행위는 거래의 안정성을 크게 해치고 거래상대방에게 불이익을 주는 행위’라면서 公社에 대하여 ‘거래상 지위남용 행위’에 대한 시정조치 및 과징금 부과 처분을 하였다.

그러나 公社는 처분의 위법성·부당성을 다투고자 처분 취소를 구하는 소송을 제기하여 [표 40]과 같은 취지로 위의 시정조치 및 과징금 부과 처분에 대한 취소 판결을 받았다.

[표 40] 공정위 처분에 대한 소송 판결 취지

사건 처분의 적법 여부에 관한 판단
공사계약특수조건이 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건에 해당하지 않는 한 <u>이미 설계가 변경되어 시공이 완료된 이후라고 하더라도</u> 종전에 잘못 산정된 공사비에 대하여 <u>공사계약특수 조건에 따라</u> 단순한 오류를 바로잡는 차원에서 <u>조정 또는 환수하는 것이 가능</u> 하다고 판단되고, 오류 금액을 조정하거나 환수하였다고 하여 원고가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방에게 불이익을 준 것이라고 보기는 어렵다

자료 : 最高法院 判決文(2016. 12. 14.) 재구성 (공정위에서 대법원 상고하였으나 2017. 5. 12. 기각)

설계변경 및 시공 완료 이후라고 하더라도 잘못 산정된 공사비에 대하여 계약 조건에 따라 환수하는 것이 가능하며 이는 상대방에게 불이익을 주는 것이 아니라는 판결 취지를 고려할 때, 계약조건에 따라 설계변경 대상이 되지 않는데도 시공 완료 후 부당한 설계변경을 함으로써 과다하게 지급된 공사비를 회수하는 조치

는 적법하며 불공정 행위에 해당되지 않는다고 판단된다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

부적정한 설계변경으로 인하여 과다 지급된 공사비 985백만 원을 회수하시기
바랍니다(시정((회수)).